Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0834731-15.2019.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Ailton Amaral de Freitas
Requerido: São Francisco Sistema de Saúde S/A Ltda

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

AILTON AMARAL DE FREITAS, com qualificação nos autos, propôs **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** em face de **SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/A LTDA**, também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"c) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) à título de danos morais, com fundamento no artigo 6, inciso VI, da Lei 8.078/1990;***
>
> ***f) Por fim, requer que seja julgada totalmente procedente a presente demanda, confirmando a decisão concedida em tutela de Urgencia, para que seja a Requerida obrigada a autorizar e custear toda a medicação necessária ao procedimento quimioterápico, em especial a "Bendamustina" (RIBOMUSTIN™) até o fim do tratamento do linfoma".***

Como causa de pedir, sustenta que é beneficiário do plano de saúde da parte requerida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Esclareceu que, na data de 28/02/2019, foi diagnosticado com linfoma não-hodgkin folicular (CID10 – C82), tendo iniciado o tratamento através de quimioterapia.

Sustentou que o tratamento foi interrompido, visto que o mesmo apresentou uma reação alérgica a um dos componentes do medicamento 'MABTHERA', denominado "Rituximabe'.

Relatou que ao receber a dose do medicamento, sofreu uma parada respiratória em decorrência da alergia apresentada, bem como que, passados alguns dias, o médico tentou aplicar a medicação novamente, utilizando remédios antialérgicos, no entanto, novamente sofreu parada respiratória.

Informou que o médico optou seguir o tratamento sem o uso do referido medicamento, no entanto, o tratamento não surtiu efeito e a doença se agravou.

Relatou que, por tais motivos, o médico Luiz Henrique Mascarenhas Moreira indicou a substituição do componente "MABTHERA' - 'Rituximabe' por um composto proveniente da associação de 'RIBOMUSTIN (Bendamustina' e 'GAZYVA (Obinutuzumabe)', visto que tal medicação é indicada especificamente para pacientes que não tenham respondido ou recaído durante o tratamento com "Rituximabe'.

Afirmou que solicitou à parte requerida a autorização para a realização do tratamento nos termos solicitados pelo médico, no entanto, a requerida não autorizou a medicação 'Bendamustina – Ribomustin', sustentando o seguinte: *"O procedimento ou serviço (acima especificado no item 4) solicitado pelo beneficiário (acima referenciado no item 01) através do protocolo (acima registrado no item 03) não foi autorizado porque o contrato de seu plano de saúde é regulamentado e a operadora apenas tem obrigação legal de procedimentos e serviços previstos na Lei 9.656, de 1998, e em seus regulamentos. E neste caso, sua solicitação não consta do Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nem das*

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 2º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

eventuais cláusulas adicionais de seu contrato".

Relatou que encaminhou e-mail à requerida solicitando a reanálise do pedido, no entanto, a requerida novamente indeferiu a realização do tratamento com o uso da medicação 'Bendamustina – Ribomustin', sustentando que tal procedimento é considerado "off-label".

Esclareceu que o tratamento solicitado é autorizado e regulamentado pela ANVISA, bem como é o meio mais seguro para garantir a sua saúde.

Esclareceu que, tentou por diversas formas a autorização do tratamento, no entanto, não obteve êxito.

A parte ré foi citada (fl. 229), sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 276/298), alegando, em síntese o seguinte: 1) aduz que o tratamento requerido pelo autor não é indicado para a sua patologia, sendo definido como *off label;* 2) sustenta que o medicamento não está incluso no rol da ANS; 3) afirma a ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento requerido; 4) aduz que não praticou nenhum ato ilícito; 5) sustenta que é dever do Estado fornecer o medicamento requerido pelo autor, inclusive, o mesmo é fornecido pelo SUS; 6) afirma que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; 7) inexistência de danos morais; e 8) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 342/355.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fl. 275).

Na fase de organização e saneamento do feito, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 377/380) e a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial e documental (fls. 374/375).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese a parte requerida pugnar pela produção de prova pericial, com a finalidade de comprovar a efetividade do tratamento requerido ao autor, tal requerimento deve ser indeferido.

Com efeito, a realização de perícia para provar a alegação de que o tratamento requerido pelo autor não era indicado à sua patologia é desnecessária, uma vez que o pedido está amparado em laudo do profissional que o acompanhava.

Ademais, o pleito nos termos em que está formulado, aparentemente, busca firmar uma premissa de julgamento para o feito, o que é processualmente inadequado, posto que constituiria tentativa de obter um "parecer" para substituir a prescrição do médico que realiza o tratamento do autor.

Ressalta-se que, na atividade de julgar, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ***"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"***, de modo que a análise de eventual obrigação de fazer deve ser realizada levando-se em consideração as resoluções atinentes ao caso e ao Código Civil.

Na espécie, incide o disposto no at. 355, I, do Código de Processo Civil, no qual assevera que "***O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas".***

Logo, **INDEFIRO** a produção de prova pericial requerida pela parte ré e passo analisar ao mérito da ação.

II.I – MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

qual a parte autora busca a condenação da requerida em proceder o fornecimento do medicamento "BENDAMUSTINA – RIBOMUSTIN" durante o tratamento quimioterápico, bem como a condenação no pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3º, § 2º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 608, ***"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".***

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda.*

No presente caso, o autor afirma que foi diagnosticado com linfoma não-hodgkin folicular (CID10 – C82), tendo iniciado o tratamento através de quimioterapia.

Sustentou que o tratamento foi interrompido, visto que o mesmo apresentou uma reação alérgica a um dos componentes do medicamento 'MABTHERA', denominado "Rituximabe'.

Relatou que ao receber a dose do medicamento, sofreu uma

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

parada respiratória em decorrência da alergia apresentada, bem como que, passados alguns dias, o médico tentou aplicar a medicação novamente, utilizando remédios antialérgicos, no entanto, novamente sofreu parada respiratória.

Informou que o médico optou seguir o tratamento sem o uso do referido medicamento, no entanto, o tratamento não surtiu efeito e a doença se agravou.

Relatou que, por tais motivos, o médico LUIZ HENRIQUE MASCARENHAS MOREIRA indicou a substituição do componente "MABTHERA' - 'Rituximabe' por um composto proveniente da associação de 'RIBOMUSTIN (Bendamustina' e 'GAZYVA (Obinutuzumabe)', visto que tal medicação é indicada especificamente para pacientes que não tenham respondido ou recaído durante o tratamento com "Rituximabe'.

Afirmou que solicitou à parte requerida a autorização para a realização do tratamento nos termos solicitados pelo médico, no entanto, a requerida não autorizou a medicação 'Bendamustina – Ribomustin', sustentando o seguinte: *"O procedimento ou serviço (acima especificado no item 4) solicitado pelo beneficiário (acima referenciado no item 01) através do protocolo (acima registrado no item 03) não foi autorizado porque o contrato de seu plano de saúde é regulamentado e a operadora apenas tem obrigação legal de procedimentos e serviços previstos na Lei 9.656, de 1998, e em seus regulamentos. E neste caso, sua solicitação não consta do Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nem das eventuais cláusulas adicionais de seu contrato".*

Relatou que encaminhou e-mail à requerida solicitando a reanálise do pedido, no entanto, a requerida novamente indeferiu a realização do tratamento com o uso da medicação 'Bendamustina – Ribomustin', sustentando que tal procedimento é considerado "off-label".

Esclareceu que o tratamento solicitado é autorizado e regulamentado pela ANVISA, bem como é o meio mais seguro para garantir a sua saúde.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

Esclareceu que, tentou por diversas formas a autorização do tratamento, no entanto, não obteve êxito.

A requerida, por sua vez, sustenta que o tratamento requerido pelo autor não é indicado para a sua patologia, sendo definido como *off label*, bem como que tal tratamento não está incluso no rol da ANS.

Em que pese a manifestação da requerida, tal tese não merece prosperar.

É cediço que não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, constituindo tal ato verdadeira cláusula abusiva, que afronta diretamente as normas protetivas previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

> ***"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***
>
> ***I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis***
>
> ***II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;***
>
> ***III - transfiram responsabilidades a terceiros;***
>
> ***IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;***
>
> ***VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;***
>
> ***VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;***
>
> ***VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;***
>
> ***IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;***
>
> ***X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;***
>
> ***XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias".

Dessa maneira, verifica-se que é obrigação do plano de saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

Nesse sentido tem-se os seguintes julgados:

"PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR (OBINUTUZUMABE E BENDAMUSTINA). O E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP), estabeleceu que a negativa de cobertura é lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não registrados ou autorizados pela ANVISA: "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA".Medicamentos prescritos à autora registrados na ANVISA. Limitação de cobertura que não se estende ao medicamento devidamente registrado prescrito ao paciente de forma diversa daquela que consta na bula (off label). Cobertura devida. Ação procedente. V. acórdão mantido" ([1]).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Segundo o entendimento desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei n° 9.656/1998 se submetem às normas do CDC para o fim de aferir eventual abusividade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas. 3. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerando essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 4. No caso, o tribunal de origem, com base nos

[1] TJSP - APEL. Nº: 1129224-09.2016.8.26.0100- COMARCA: SÃO PAULO – 10/04/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da Súmula n° 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido" ([2]).

"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para recuperação da saúde de um paciente. 2. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura" ([3]).

"E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÍNDROME MIELODISPLÁSTICAS DO SUBTIPO ANEMIA REFRATÁRIA – DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA – URGÊNCIA DA MEDIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA PATOLOGIA QUE PROGRIDE COM POSSIBILIDADE DE ÓBITO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C 138, IV, DO RITJMS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Diante da autorização de se proferir decisões monocráticas, concedida pela junção dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 com o art. 138, IV, do RITJMS, não há que se falar em nulidade. Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum que negou provimento de plano ao recurso ante a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios" ([4]).

Dessa forma, a requerida não poderia negar o fornecimento do tratamento pretendido, indicado por médico responsável pelo acompanhamento da saúde do requerente (fl. 81).

---

[2] AgRg no AREsp Nº 475.558/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015

[3] Agravo de Instrumento - Nº 1406439-42.2017.8.12.0000 - Dourados Relator : Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 25/07/2018.

[4] Agravo Interno - Nº 2000334-79.2018.8.12.0900/50000 - Bela Vista - Relator – Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 25/07/2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

Ademais, são indiscutíveis os benefícios da realização de tal tratamento para estancar a evolução da doença, logo, não se visualiza qualquer justificativa plausível a negativa no fornecimento do referido exame.

No que tange a alegação de que o medicamento requerido não está previsto no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, a mesma não merece prosperar, uma vez que a listagem feita pela agência reguladora não é taxativa.

Isto porque, cuida-se de uma relação mínima, de uma lista de consultas, exames e tratamentos que os planos de saúde contratados a partir de 02 de janeiro de 1999 são obrigados a fornecer.

O rol da ANS é meramente exemplificativo e, havendo expressa indicação médica, como ocorreu na espécie, é abusiva a negativa de cobertura de custeio do medicamento pretendido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou em caso semelhante:

> ***"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido" ([5]).

De igual modo, a alegação da requerida de que inexiste previsão contratual para o fornecimento de medicamentos "off label", ou seja, fora da indicação contida na bula, não merece prosperar, haja vista que quem melhor possui condições de conhecer a respeito da necessidade do tratamento é o profissional de saúde que atende diretamente o paciente.

Assim, considerando que o laudo médico (fl. 81) apresenta evidências suficientes de que o medicamento é eficaz e bem tolerado no tratamento da doença em questão, inclusive para pacientes refratários, exatamente a situação dos autos.

Portanto, comprovada a necessidade da utilização do medicamento "BENDAMUSTINA – RIBOMUSTIN" no tratamento quimioterápico do autor e não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico do paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora.

O autor pugna, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento à titulo de danos morais, tendo em vista que essa recusa indevida da cobertura do plano de saúde, ocorreu em um momento delicado de sua vida, causando-lhe diversos transtornos.

Para que exista o dever de indenizar, como é sabido, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil, tais sejam: ação

[5] **STJ** - AgRg no REsp 1546908 / RS, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 03/05/2016.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

Nesse sentido são as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil vigente, que, assim dispõem:

> ***"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".***
>
> ***"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".***

Logo, provada existência da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que cause prejuízo a outrem, o responsável pela violação fica obrigado a reparar o dano causado.

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([6]).

No caso dos autos, tais elementos restaram devidamente provados e justificam o julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Com efeito, as provas produzidas evidenciaram a necessidade do medicamento solicitado pelo médico do autor, mas houve falha na prestação de serviço, na contramão da função social do contrato e do âmago da sua essência.

A propósito, importante destacar o julgado do Tribunal de Justiça deste Estado, a seguir transcrito:

---

[6] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – TRANSPLANTE DE RIM – DIREITO AO REEMBOLSO DO TOTAL DAS DESPESAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, RECURSO CONHECIDOS, RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). No caso específico, não há como negar a cobertura do total das despesas com o procedimento (transplante de rim), uma vez que definidos os valores de reembolso mediante critérios inespecíficos cujas informações não foram devidamente repassadas ao consumidor. (...) Na hipótese, restaram configurados os pressupostos necessários à configuração dos danos de ordem moral, porquanto a injusta recusa de cobertura de plano de saúde aumentou o sofrimento do segurado, que inegavelmente ficou abalado emocionalmente diante da recusa de cobertura para que realizasse a cirurgia que necessitava transplante de rim - procedimento essencial para o restabelecimento de sua saúde (...)" ([7]).***

Vê-se que o autor é pessoa de poucos recursos e está realizando tratamento oncológico, de modo que a negativa à realização do medicamento lhe causou manifesto sofrimento desnecessário.

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelo requerente, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

Deve ser considerado que a requerida é uma empresa de serviços médicos de grande porte, com grande número de clientes, que tem condições de prevenir a ocorrência de semelhantes ilícitos com tecnologia e mão de obra especializada, mesmo assim acabou por violar o direito da parte autora.

O valor fixado deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV, desde a data desta sentença, com fim de preservar-se ante a espiral inflacionária.

---

[7] **TJMS.** Apelação n. 0800769-47.2015.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 12/12/2017, p: 18/12/2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

Observo que a atualização monetária não constitui um *plus* no débito, mas mera recomposição de valores ante à espiral inflacionária, sendo adequada a utilização do IGPM/FGV, posto que se trata de índice que reflete a efetiva variação do custo de vida.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, nos termos da jurisprudência do STJ (Recurso Especial nº 903258/RS), o termo inicial dos juros de mora em reparação por danos morais deve ser a partir da fixação do valor da indenização.

O percentual dos juros moratórios deve corresponder a 1% (um por cento) ao mês, visto que se aplica ao caso disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (Enunciado 20 do CEJ).

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** formulados na petição inicial para o fim de:

1) condenar a requerida em fornecer o medicamento "BENDAMUSTINA – RIBOMUSTIN" durante o tratamento quimioterápico do autor e, por consequência, ratifico os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência de fls. 209/217;e

2) condenar a parte ré no pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor deverá ser corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV desde a data desta sentença, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também desde a data desta sentença.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.

processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (atendimento na Comarca), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e os atos processuais praticados (feito não instruído), fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2º, I a IV, do Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 20/10/2020 às 18:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0834731-15.2019.8.12.0001 e código 6SgLKXC6.